

1511202-26.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, o encontro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511202-26.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511202-26.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124450/2022 - 73º D.P. JACANA, 24811866 - 73º D.P.

JACANA, 2124450 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATRA ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 717.22

VISTOS.

JHONATRA ALVES DOS SANTOS, qualificado à fl. 04, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta que no dia 06 de maio de 2022, às 22h05min, na rua Ari da Rocha Miranda, nº 611, Conjunto Habitacional Jova Rural, nesta Capital, , trazia consigo 03 porções de maconha (massa líquida 5,9g), e 71 porções de cocaína (massa líquida 23,1g), drogas em desacordo com autorização legal ou regulamentar, destinada ao tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida à fl. 69.

Defesa Preliminar devidamente apresentada.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, uma testemunha de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos

exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, dando conta dos 03 invólucros de maconha, dos 71 invólucros de cocaína, além de R\$ 365,00, encontrados em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 76, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahidrocannabinol e cocaína.

A autoria também é inconteste.

De fato, os argumentos de sua defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia o réu permaneceu calado. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu forneceu sua versão dizendo que eu confesso que estava mesmo com a sacola de drogas, igual ao policial falou. Estou arrependido, a droga era para venda. Já foi condenado por uma extorsão. Não conhecia os policiais. Tenho 26 anos de idade.

É certo que a confissão sozinha não se presta a sustentar todo édito condenatório. Mas é certo também que quando vem acompanhada pelas demais provas dos autos, como no presente caso, pode e deve ser considerada como útil elemento de convicção.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado.

Mesmo porque, não se pode crer que o réu estivesse com tamanha quantidade e variedade de drogas, além de dinheiro, em seu poder, não fosse para o exercício da traficância.

Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, o encontro de dinheiro, a atitude suspeita do réu, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que um dos policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Pedro Henrique Batista Munhoz Assis, relatou, de forma firme e segura que estávamos em patrulhamento de rotina, a caminho da base, quando notamos a presença do réu.

Quando nos viu, ele entrou em uma via paralela, então retornamos para abordar. Ele soltou uma sacola no chão, caminhou dois ou três metros, e foi abordado. No interior da sacola foram encontradas as drogas. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente. O réu confessou informalmente que havia comprado a droga para revenda.

Os policiais militares narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde patrulhamento de rotina, a atitude suspeita do réu ao avistar os policiais e dispensar uma sacola, sua abordagem, a grande quantidade de drogas encontradas na sacola, o encontro do dinheiro, sua confissão informal, até final detenção e prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se

prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos.

Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros. Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, o fato do réu ser também usuário e estar vendendo para sustentar seu vício, em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes usuários devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil para sustentarem seus vícios, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários. Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59, dolo normal à espécie. Nesta primeira fase fixo sua pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase o réu é reincidente numa extorsão, conforme certidão de fls. 32.

De outro giro, confessou espontaneamente a autoria do crime, de sorte que mantenho a pena base, eis que tais circunstâncias, a meu ver se compensam. Não se ignora que a lei determina de forma expressa que a reincidência é causa preponderante sobre a confissão. Ocorre porém que em decisão recente, o STJ unificou entendimento no sentido contrário, qual seja, ambas circunstâncias são preponderantes, posição que compartilho e mostra-se mais adequada para individualização da pena. Ora, não se

pode negar que com a confissão, o acusado demonstra seu interesse em colaborar com a elucidação dos fatos, enquanto aqueles que negam, buscam eximir-se da responsabilidade penal, não podendo assim, ambos serem tratados de forma igual. O valor de cada dia multa será o mínimo legal.

Não há que se falar em aplicação da redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o condenado é reincidente, foi detido com grande quantidade de drogas, circunstâncias estas suficientes a afastarem os requisitos subjetivos necessários para o reconhecimento e aplicação da redução em apreço, nada havendo portanto, que demonstre que não faz do crime um meio de vida.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “ O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida – 13 (treze) pedras de crack – justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3” (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). Pelo mesmo motivo, incogitável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxico, tendo em vista circunstância judicial desfavorável atinente à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas (TJESP, Apelação Criminal nº 0006187-64.2012.8.26.0176, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO; STF, RHC 94.806/PR; STJ, HC 105.216/SP e 141.921/SP), porquanto o expressivo (e variado) “carregamento” denota estreita vinculação do réu com organização destinada ao tráfico.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JHONATRA ALVES DOS SANTOS, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente fechado, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade fechado, pois além da reincidência, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo e o artigo 2º, §1º da Lei 8072/90 prevê expressamente, que crimes dessa natureza, terão suas penas cumpridas inicialmente em regime fechado. Além do mais, tratando-se de crime equiparado a hediondo, elencado pela Constituição Federal como inafiançável, sendo vedada a liberdade provisória, antes da condenação definitiva, quando prevalece a presunção de inocência, muita mais descabida é a concessão de qualquer regime diverso, com possibilidade de liberdade cautelar àquele que vem a ser condenado, mesmo que em primeiro grau.

Não é possível também a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever:

“Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: “inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi

tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal. Qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade e em regime fechado, mostrar-se-ia por demasiado tênue, como forma de repressão e retribuição.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, o condenado respondeu a todo o processo preso e assim deve permanecer, pois foi nesta data condenado a crime de extrema gravidade, dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06.

A sociedade está aterrorizada com o crescente aumento da criminalidade, em especial, da prática de crimes como deste jaez, cujos agentes não se privam em aliciar jovens em nossas comunidades, causando transtornos irreparáveis em todos os cidadãos de bem.

Assim sendo, presentes os requisitos legais, não concedo ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo por fim de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o regime fechado não se deu unicamente em razão do tipo de crime.

No sentido: Apelação nº 0016847-49.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são apelantes SIDNEI VALADARES ARAUJO, PEDRO DA SILVA AZEVEDO, DIEGO FERNANDES DAS DORES e LORRAINE CAROLINE ALVES CORTEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ACORDAM, em 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso do réu Pedro por ausência de interesse recursal e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos demais réus, com determinação. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA (Presidente) e RICARDO TUCUNDUVA Ementa: "RECURSO - trancamento da ação penal em relação a um dos réus reconhecida a litispendência - ausência de interesse recursal - não conhecimento do recurso de Pedro. NULIDADE - adotado rito da lei especial que prefere o rito ordinário - previsão legal - ausência de prejuízo - preliminar afastada. NULIDADE - interceptação telefônica - alegada ilegalidade das interceptações telefônicas por se tratar de medidas excepcionais - legalidade das informações - ausência de transcrição das conversas interceptadas - disponibilizado o acesso da mídia às partes - longo lapso temporal da interceptação necessário para comprovar a estabilidade da associação - ausência de irregularidades - preliminares afastadas. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - materialidade e autoria comprovadas pelo depoimento dos policiais, que individualizaram a função de cada um dos réus na associação e demonstraram a permanência e estabilidade da mesma - manutenção da condenação dos apelantes. PENAS - base acima do mínimo dada a natureza da droga comercializada pela associação - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - aumento na segunda fase pela reincidência para um dos réus - regime fechado mantido ante a maior culpabilidade dos agentes, na forma do art. 33, § 3º, CP - descabimento da

detração porque o regime não foi fundada apenas no quantum de pena, mas sim nas circunstâncias do crime – improvimento dos demais recursos.”

Além disso não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional que se encontra recolhido.

Declaro a destruição dos entorpecentes apreendidos.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 25 de agosto de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA